

- **Expediente nº.: EXP202309208**

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN

Examinado el recurso de reposición interpuesto por EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. contra la resolución dictada por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 19 de junio de 2024, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19/06/2024, se dictó resolución por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente EXP202309208, en virtud de la cual se imponía a EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. (en lo sucesivo EL ESPAÑOL o la parte recurrente) las multas siguientes:

. Por una infracción del artículo 5.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo RGPD), tipificada en el 83.5 del citado RGPD, y calificada como muy grave a efectos de prescripción en el artículo 72.1.a) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo, LOPDGDD), una multa de 10.000 euros (diez mil euros).

En la misma resolución se acordó elevar a definitiva la orden de adopción de medidas acordada en fecha 09/09/2022, durante las actuaciones previas de investigación, y confirmada en el acuerdo de apertura del presente procedimiento sancionador, la cual había sido atendida por la entidad EL ESPAÑOL retirando definitivamente el contenido objeto de las actuaciones.

Dicha resolución, que fue notificada a la parte recurrente en fecha 20 de junio de 2024, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en la LOPDGDD, y supletoriamente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), en materia de tramitación de procedimientos sancionadores.

SEGUNDO: Como hechos probados del citado procedimiento sancionador, PS/00335/2023, quedó constancia de los siguientes:

*<<PRIMERO: Con fecha ***FECHA.1, un usuario de la red social "Twitter" publicó en su perfil un vídeo consistente en un montaje de tomas sucesivas (...). La imagen y la voz de la parte reclamante se apreciaba con toda nitidez en dicha grabación.*

SEGUNDO: La parte reclamante ha declarado que la publicación del vídeo reseñado en el Hecho Probado Primero se realizó sin su consentimiento.

*TERCERO: Con fecha ***FECHA.2, la entidad EL ESPAÑOL publicó en su web*

*“elespanol.com” una noticia sobre la divulgación en redes sociales del video reseñado en el Hecho Probado Primero. Esta noticia, que se encontraba accesible a través de la URL (“***URL.1”) incluía una imagen de la parte reclamante capturada de aquel vídeo y el texto siguiente:*

<<(fotografía capturada del vídeo, que corresponde a una imagen de la parte reclamante, con el pie de foto “(...))

“(...)”.

CUARTO: Con fecha 14/09/2022, en cumplimiento de la medida provisional adoptada por la AEPD, EL ESPAÑOL retiró la noticia reseñada en el Hecho Probado Tercero, impidiendo su acceso tanto de manera externa como a través del buscador interno del periódico.

*QUINTO: Los Servicios de Inspección de la AEPD han constatado que el vídeo reseñado en el Hecho Probado Primero se viralizó tras su publicación el ***FECHA.1 en Twitter. Debido a esa amplia difusión, podía encontrarse en decenas de sitios y localizarse fácilmente con un motor de búsqueda utilizando etiquetas como “(...)” o “(...)”.>>*

TERCERO: Con fecha 19/07/2024, dentro del plazo establecido, se ha interpuesto recurso de reposición por EL ESPAÑOL contra la resolución reseñada en el Antecedente Primero, de fecha 19/06/2024, en el que pone de manifiesto las mismas circunstancias y consideraciones recogidas las alegaciones formuladas durante la tramitación del procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada y solicita que se determine la nulidad de la resolución sancionadora o, subsidiariamente, que se rebaje la cuantía de la multa impuesta.

De lo expuesto en el recurso planteado cabe destacar las manifestaciones siguientes:

1. Obligaciones de EL ESPAÑOL como responsable del tratamiento.

No niega la aplicación a su actividad de la normativa de protección de datos personales, como así lo prueban las acciones que ha venido realizando con el objetivo de garantizar los derechos de los interesados, pero defiende que los principios recogidos en el artículo 5 del RGPD deben ser aplicados de forma flexible, dada la naturaleza de su profesión y la importancia de los medios de comunicación para el desarrollo de una sociedad libre y plural. Esto obliga, en muchas ocasiones, a publicar datos personales que resultan necesarios para proporcionar una información completa, contextualizada y de interés público, de forma proporcional al derecho a la libertad de información.

Ante la existencia de un hecho noticioso, los principios de protección de datos pueden verse limitados y ponderados, resultando recomendable distinguir la interpretación de la norma cuando entra en juego el ejercicio de derechos constitucionales como elemento nuclear de la conducta investigada frente a cuando la entidad actúe como cualquier otra organización con ánimo de lucro.

Deberá respetarse la definición constitucional del derecho a la libertad de información

y sus requisitos legitimadores, como ha reflejado el legislador al incluir en los Considerandos 4 y 153, así como el artículo 85, del RGPD, la posibilidad de incluir excepciones a la normativa de protección de datos cuando se realiza un tratamiento con fines exclusivamente periodísticos, por cuanto dicha actividad conlleva una mayor exposición a realizar tratamientos que puedan afectar a los derechos de los interesados.

Destaca que es un hecho pacífico que la libertad de expresión e información alcanza su máximo nivel cuando es ejercitada por los profesionales de la información (STC 165/1987), mientras que la resolución sancionadora califica la conducta en ese caso como imprudente, exigiendo un mayor grado de diligencia por la profesionalidad del sujeto, basándose para ello en una sentencia de la Audiencia Nacional dictada en un supuesto de inclusión de datos personales en el fichero Asnef.

Entiende, por tanto, EL ESPAÑOL que el análisis deberá realizarse analizando si concurren los requisitos legitimadores del derecho ejercitado y no si concurre una previsión legal en el vacío a la que anudar una infracción que prescinde de la necesaria ponderación a la luz de los hechos acreditados en la conducta del denunciante, su relevancia informativa.

La imposición de una sanción puede coartar el ejercicio de un derecho constitucional cuando en el mismo concurren sus requisitos legitimadores.

Añade que la interpretación estricta del principio de minimización de datos somete a la actividad informativa a contornos difusos que impondrían a los medios de comunicación unas obligaciones de imposible ejecución.

No niega el necesario análisis previo de las noticias que va a publicar, pero considera desproporcionado la realización de un análisis de riesgos en los términos establecidos en la normativa de protección de datos, cuando en la resolución dictada se prescinde del análisis de los requisitos de relevancia, interés público y veracidad. Así, destaca que el vídeo es veraz, fue difundido con fines promocionales y se hizo viral. Por tanto, considera que el análisis de riesgos deberá ser realizado con sometimiento a los requisitos constitucionales que autorizan el derecho ejercitado y no como sostiene la resolución impugnada.

Además, la medida expuesta por la resolución resulta desproporcionada en términos de costes y, por ello, contraria a lo establecido en el artículo 32 del RGPD.

“Evidentemente, todas las noticias son analizadas previamente, a efectos de determinar la relevancia pública e interés informativo de la misma y ello no puede ser confundido, como parece hacer la AEPD, con un juicio en el que prescindiendo de los primeros el análisis se sustente en una normativa que por afectar de forma determinante a un derecho constitucional deberá quedar sometida a la concurrencia de sus requisitos legitimadores, y no al revés”.

2. Pertinencia de los datos personales publicados

Afirma la resolución sancionadora, respecto de los criterios de relevancia pública, interés general y veracidad, que están relacionados con el derecho regulados por la

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. Sin embargo, dichos criterios se han venido ponderando por la propia AEPD, en cuanto habilitantes del derecho invocado (Resolución E/03409/2018).

A) Condición de personaje público del interesado.

La viralización del vídeo en cuestión, que ya se había producido cuando se publica la noticia, elimina la condición de “particular anónimo” del interesado.

Es una situación que hace referencia al concepto de relevancia sobrevenida, ya aludido en las alegaciones a la propuesta de resolución, junto a diversas resoluciones judiciales que determinan la existencia de legitimación para la publicación de la imagen de una persona anónima; criterios ambos a los que no hace mención la resolución sancionadora.

Por otra parte, insiste en señalar que no se entiende que la resolución sancionadora mantenga que no es posible acreditar la participación de la parte reclamante en la viralización del vídeo.

B) Necesidad del uso y difusión de la imagen y voz del interesado

EL ESPAÑOL aprecia un cambio de criterio que supone una quiebra constitucional en cuanto implica un control de contenidos informativos desde el ámbito administrativo.

El precedente E/03409/2018, de resolución de archivo de actuaciones, ya citado en el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, ya advierte que el control administrativo sobre los contenidos de las informaciones publicadas por medios de comunicación es incompatible con nuestro sistema constitucional.

Sin embargo, la resolución impugnada declara que la información publicada no requería la utilización y difusión de datos personales y que mantener la imagen y voz sin anonimizar no aporta valor añadido alguno a la información.

Con ello, la resolución realiza ponderaciones acerca de la proporcionalidad de los datos personales publicados y su valor informativo, valorando que la noticia tendría el mismo interés periodístico si se hubiese realizado esa anonimización. Considera EL ESPAÑOL que esto es contrario al principio de legalidad y a lo dispuesto en la resolución de archivo citada.

Al contrario de lo señalado en la resolución recurrida, el proceso de anonimización del vídeo desnaturalizaría el contenido mismo y su interés informativo, impidiendo al lector de EL ESPAÑOL obtener una información contextualizada. La noticia precisamente lo que describe es el propio vídeo y las reacciones de los usuarios, que no tendrían ningún valor si el lector no fuera conocedor del vídeo (...).

Invoca el artículo 3 del Código Civil para señalar que la interpretación de la norma debe realizarse en relación al momento en el que esta debe ser aplicada y las condiciones sociales imperantes.

En resumen, a juicio de EL ESPAÑOL, la anonimización limitaría su derecho a la

libertad de información.

C) Accesoriedad de las imágenes. Infracción del artículo 32

Aunque relacionado con el derecho al honor, intimidad y propia imagen, el concepto de accesoriedad debe ser valorado al aplicar la normativa de protección de datos, en cuanto implica una limitación del derecho a la imagen, de rango constitucional, que no puede ser obviada en la ponderación de derechos a realizar.

Cita la Sentencia del Tribunal Supremos 241/2003, de 14 de marzo, para señalar que la accesoriedad protege que las imágenes que acompañan una noticia tengan relación directa con la misma o, lo que es lo mismo, que los datos personales que ilustran la información sean necesarios para describir en imágenes la conducta pública aludida. En base a esto, entiende EL ESPAÑOL que existe una relación analógica entre la accesoriedad y la minimización de datos asociada a la materia informativa.

El vídeo en cuestión cumple con este requisito, no por aparecer la persona del aludido, sino por ser el vídeo que esencialmente era el objeto informativo, no siendo posible entender la noticia sin la publicación del vídeo.

A este respecto, hace referencia a lo indicado en su escrito de alegaciones, sobre la relación del presente caso con el analizado en la Sentencia del Tribunal Supremo 593/2022, de 28 de julio, relativa a la publicación por un medio de comunicación de un vídeo subido a Youtube con la anuencia del actor, siendo necesarias las imágenes para contextualizar al lector.

En este caso, el vídeo fue inicialmente subido a redes sociales con la anuencia de la parte reclamante, donde resultaba accesible para todos los usuarios, y es este vídeo el objeto central de la noticia.

3. Determinación del importe de la sanción.

Respecto de esta cuestión, EL ESPAÑOL reitera lo siguiente:

. No es posible aceptar la existencia de negligencia por la publicación de unos datos personales justificada por el interés informativo de los mismos, sin los cuales la noticia carecería de sentido y sería incompleta, debiendo considerarse, además, la actividad que lleva a cabo un medio de comunicación y que se enfrentan dos derechos fundamentales cuya ponderación es controvertida.

. Con la retirada de la noticia se alcanzó la finalidad de la reclamación interpuesta, en tanto que era impedir una mayor difusión de un vídeo que ya resultaba viral, de modo que los derechos del interesado ya se han visto protegidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia

Es competente para resolver el presente recurso la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP) y el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo, LOPDGDD).

II

Contestación a las alegaciones presentadas

En relación con las manifestaciones efectuadas por la parte recurrente, que reproducen básicamente las alegaciones presentadas por la misma durante la tramitación del procedimiento sancionador, sin añadir ningún argumento nuevo, debe señalarse que ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II a VII de la Resolución recurrida, de fecha 19/06/2024, en la que se considera que la misma incumplió lo dispuesto en el artículo 5.1.c) del RGPD y se detalla suficientemente la valoración de las pruebas que han permitido determinar dicho incumplimiento y el alcance otorgado al mismo, así como las circunstancias tenidas en cuenta para la graduación de la sanción impuesta. En dichos Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente:

<<II

Respuesta a las alegaciones a la propuesta de resolución

1. Obligaciones de un medio de comunicación como responsable del tratamiento. Requisitos para la publicación de datos personales por parte de medios de comunicación.

Comienza EL ESPAÑOL su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución destacando que la normativa de protección de datos personales se encuentra limitada frente al ejercicio periodístico, por la posición esencial que para la sociedad adquiere el derecho a la libertad de expresión e información, y que la jurisprudencia otorga a los profesionales de la información una protección específica al estar sometidos a mayores riesgos (STC 225/2009, de 9 de diciembre).

Y continúa indicando que, por el contrario, la propuesta de resolución da a entender que las obligaciones de EL ESPAÑOL como responsable del tratamiento se ven ampliadas desde el momento en que su actividad está basada en el ejercicio del periodismo, afirmando que viene especialmente obligada a considerar los riesgos que supone la difusión de imágenes y voz a través de un medio de comunicación; o que debería haberse planteado si la finalidad de la información requería la difusión de la imagen y la voz de la parte reclamante; o la obligación de realizar un análisis de riesgos previo a la publicación de la noticia.

No niega esta Agencia que el derecho fundamental a la protección de datos personales, como todos los derechos, se encuentre limitado por otros derechos fundamentales, en este caso por la libertad de expresión e información. Es esta circunstancia la que obliga, en cada caso concreto, a ponderar o conciliar los derechos en conflicto.

Así se dispone, precisamente, en los Considerandos 4 y 153 y el artículo 85 del RGPD invocados por EL ESPAÑOL cuando señalan que el derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión e información, incluida la expresión periodística. Hasta tal punto que el Considerando 153 y el artículo 85 del RGPD, no solo obligan a los Estados miembros a conciliar las normas que rigen estos otros derechos con el derecho a la protección de los datos personales con arreglo al RGPD, sino también a adoptar medidas legislativas que establezcan excepciones o exenciones de determinadas disposiciones de dicho Reglamento en relación con la cuestiones que se enumeran en estas disposiciones, entre ellas los principios generales, si así se requiere para conciliar tales derechos.

Sí niega esta Agencia, en cambio, taxativamente, que el derecho a la libertad de información limite el derecho a la protección de datos en el sentido pretendido por EL ESPAÑOL, que viene a expresar que las normas sobre protección de datos personales no se aplican cuando los tratamientos de datos se realicen en el marco de la actividad periodística, por razón del sujeto. Llega a decir que no considera necesario el análisis previo de todas las noticias que vayan a ser publicadas.

Se entienden oportunos y procedentes los argumentos defendidos en este acto, que reproducen los valorados en la propuesta de resolución, cuando se afirma que los medios de comunicación deben tener en cuenta los riesgos que conlleva el tratamiento de datos que realicen al difundir una noticia y que vienen obligados a prestar una atención especial y a establecer las cautelas necesarias para dar cumplimiento a las normas previstas para el respeto del derecho a la protección de datos personales.

Se tiene en cuenta de manera especial la profesionalidad que se atribuye al medio de comunicación, reconocida por nuestra jurisprudencia para establecer un nivel de diligencia superior en el cumplimiento de la norma. A este respecto, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17/10/2007 (rec. 63/2006) declaró que, partiendo de que se trata de entidades cuya actividad lleva aparejado en continuo tratamiento de datos, "... el Tribunal Supremo viene entendiendo que existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el infractor no se comporta con la diligencia exigible. Y en la valoración del grado de diligencia ha de ponderarse especialmente la profesionalidad o no del sujeto, y no cabe duda de que, en el caso ahora examinado, cuando la actividad de la recurrente es de constante y abundante manejo de datos de carácter personal ha de insistirse en el rigor y el exquisito cuidado por ajustarse a las prevenciones legales al respecto".

En todo caso, no es la AEPD, como señala EL ESPAÑOL, la que exige esta responsabilidad especial, sino que es la propia norma aplicable la que valora circunstancias tales como el riesgo o la profesionalidad, ya señaladas, el contexto o el estado de la técnica, entre otras.

Aceptar la posición de EL ESPAÑOL sería tanto como vaciar de contenido el derecho a la protección de datos por el simple hecho de que el tratamiento se realice por un medio de comunicación institucionalizado o por un profesional de la información, no existiendo ninguna razón de tipo económico o humano que motive la no aplicación de la norma a un sujeto obligado, ni la falta de conocimiento legal de estos profesionales

puede impedir que su actividad se vea sometida a las previsiones del RGPD y de la LOPDGDD. Tampoco puede hablarse de autocensura como una consecuencia de la aplicación de la norma, sino de cumplimiento una norma de general aplicación, que obliga también a medios de comunicación y a sus profesionales.

Hasta tanto se adopten esas medidas legislativas que definan las excepciones o exenciones a las que se refiere el artículo 85 del RGPD, los límites en la aplicación de este Reglamento y de la LOPDGDD, deberán fijarse atendiendo a las previsiones normativas y criterios interpretativos que resulten de aplicación en cada caso para llevar a cabo la indicada ponderación o conciliación de los derechos en conflicto.

Y entre estos criterios sirven los señalados por la entidad reclamada, como son la relevancia pública del sujeto interesado o su participación en el acontecimiento noticiable, la veracidad de lo publicado o su interés informativo. Pero sin olvidar, de forma prioritaria, los principios y reglas a los que se ven sometidos los tratamientos de datos personales según sus propias normas regulatorias.

Este mismo acto acude a aquellos criterios interpretativos para analizar el caso y concluir la infracción, habiendo considerado, según se expondrá más adelante, que no existía interés informativo en la difusión de los datos personales de la parte reclamante y que se trata ésta de una persona anónima. Pero, sobre todo, aplica el principio de minimización de datos regulado en el artículo 5.1.c) del RGPD y valora el contexto en el que se produce el tratamiento de datos, su finalidad y proporcionalidad respecto del fin perseguido, todo ello conforme a las normas que regulan la protección de datos personales.

Los mencionados criterios, a los que se refiere EL ESPAÑOL como requisitos para la publicación de datos personales por parte de medios de comunicación, están más relacionados con el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, en cuyos artículos 7 y 8 se establecen las actuaciones que se consideran intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por esta norma.

Al análisis de esta normativa responden aquellos criterios alegado por EL ESPAÑOL, sobre los que existe abundante jurisprudencia, a la que se puede acudir cuando se tratan aspectos de interés para decidir una cuestión en materia de protección de datos, en la medida en que ambos derechos protegen la intimidad y privacidad de las personas, pero teniendo presente siempre que se trata de criterios que sirven para orientar e informar sobre el aspecto de que se trate y cuya aplicación debe ceder frente a los principios recogidos en la normativa de protección de datos cuando se enjuicie un supuesto referido a esta materia. En definitiva, las circunstancias alegadas por EL ESPAÑOL no pueden ser las únicas valoradas, de tal modo que se excluyan las normas de protección de datos personales que resulten de aplicación.

Por otra parte, sentada la consideración general anterior, en cuanto a los “requisitos” que menciona EL ESPAÑOL, cabe indicar de contrario lo siguiente:

a) La parte reclamante es un particular anónimo y esta condición no se ve modificada por el hecho de que el contenido audiovisual publicado por EL ESPAÑOL se hubiese viralizado en redes sociales, consecuencia esta que resulta de la actuación de

terceros sin la intervención acreditada de la parte reclamante.

b) La veracidad y actualidad de la información publicada no influyen, desde el punto de vista de la protección de datos, en el uso y difusión adecuada de la imagen de la parte reclamante. Alega la parte reclamada que la noticia no se entendería de forma adecuada sin el vídeo, pero no explica cómo afectaría a la noticia la divulgación de ese contenido después de haberlo sometido a un proceso de anonimización, tal y como se defiende en este acto, ni por qué esta anonimización haría perder el interés periodístico y colisionaría con el derecho a la libertad de información.

2. Sobre la determinación del importe de la sanción propuesta.

Por las mismas razones expuestas anteriormente, debe rechazarse la solicitud de reducción del importe de la multa solicitada por EL ESPAÑOL en base a la condición del sujeto infractor, atendiendo a la protección de los profesionales de la información y la labor social llevada a cabo por el medio de comunicación, y por otro, que el contenido informativo de la noticia hubiese quedado vacío con la anonimización del vídeo.

Añade, por otra parte, que la pérdida de disposición y control de los datos personales ya había ocurrido en el momento de la publicación de la noticia, con la difusión del vídeo en redes sociales y su viralización. Circunstancia esta que no excluye que la actuación de EL ESPAÑOL tenga ese efecto y así pueda considerarse al evaluar la gravedad de la infracción.

Finamente, considera la parte reclamada que concurre como atenuante el hecho de que la noticia fuese retirada tan pronto fue requerida por la AEPD. Cita como ejemplo la resolución dictada en el expediente E/02643/2018, en el que se resolvió el archivo de las actuaciones considerando que la finalidad de la reclamación se había visto satisfecha.

Entiende esta Agencia que no son supuestos equiparables. En el presente caso, la retirada del contenido objeto de la reclamación fue ordenada por esta Agencia como medida provisional, de modo que el cumplimiento del requerimiento respectivo no se considera un factor atenuante en la graduación de la sanción.

3. Se ha procedido a la eliminación total del enlace objeto de la reclamación, de forma que no resulta accesible si quiera a través de los sistemas internos de EL ESPAÑOL.

Como se indica en los Fundamentos que siguen, con la eliminación del vídeo EL ESPAÑOL simplemente da cumplimiento a la normativa y atiende las resoluciones de esta autoridad de control, de obligado cumplimiento, de modo que dicha eliminación no sirve para modificar su responsabilidad por los hechos analizados.

III

La imagen y la voz como dato personal y otras cuestiones previas

La imagen física y la voz de una persona, a tenor del artículo 4.1 del RGPD, son un dato personal al hacerla identificable, y su protección, por tanto, es objeto de dicho RGPD:

“«datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;”

El informe 139/2017 del Gabinete Jurídico de esta Agencia afirma que “la imagen así como la voz de una persona es un dato personal, al igual que lo será cualquier información que permita determinar, directa o indirectamente, su identidad (...)”

La imagen física y la voz de una persona, a tenor del artículo 4.1 del RGPD, son datos personales y su protección, por tanto, es objeto de dicho Reglamento.

Siendo así, el tratamiento de la imagen y la voz de una persona está sujeto a la normativa de protección de datos. En el artículo 4.2 del RGPD se define el concepto de “tratamiento” de datos personales.

“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.”

La STJUE (Sala Segunda) de 14 de febrero de 2019, en el asunto C 345/17, Sergejs Buivids, declara al respecto lo siguiente:

“Cabe considerar que publicar, en un sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y compartirlos, una grabación de audio, como el controvertido, que contiene datos personales, constituye un tratamiento total o parcialmente automatizado de esos datos, en el sentido de los artículos 2, letra b), y 3, apartado 1, de la Directiva 95/46”.

Por otra parte, interesa destacar que las personas tienen el poder de disposición sobre sus datos personales, así como sobre su difusión.

Así, la STC 292/2000, de 30 de noviembre, declara que “el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos

indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos”.

IV

Obligación incumplida

La inclusión de la imagen de una persona o de un vídeo que contenga su imagen y su voz en publicaciones periódicas, en condiciones tales que la identifique o la haga identificable (sin aplicar sobre las mismas ninguna técnica que impida su identificación), en este caso, además, junto con su nombre, supone un tratamiento de datos personales. Por tanto, la entidad que efectúa este tratamiento está obligada a cumplir con los principios y obligaciones en materia de protección de datos que para el responsable del tratamiento se disponen en el RGPD y en la LOPDGDD.

Tales principios y obligaciones no decaen por encontrarnos ante un responsable del tratamiento que sea un medio de comunicación.

Es más, la entidad responsable viene especialmente obligada a considerar que la difusión a través de un medio de comunicación de la imagen y la voz de la parte reclamante y su nombre, posibilitando su identificación por terceros, implica un mayor riesgo para el interesado, siendo muy probable que pueda sufrir daños en sus derechos y libertades. Por ello, debe extremar las cautelas para que no pueda concluirse que dicho tratamiento de datos no es proporcional ni necesario en relación con las finalidades de información perseguidas.

Así, con carácter general, deberá tener en cuenta el principio de responsabilidad proactiva, establecido en el artículo 5.2 del RGPD, la valoración de los riesgos y la implementación de las medidas de seguridad adecuadas. Obligaciones que aún son más relevantes cuando el riesgo resulta especialmente sensible.

En este sentido, y con independencia de cuál sea la base jurídica legitimadora del tratamiento, todo responsable del tratamiento ha de respetar los principios del tratamiento recogidos en el artículo 5 del RGPD. En lo que al presente caso se refiere, cabe destacar el principio de “minimización de datos” recogido en el artículo 5.1.c) del RGPD, que establece lo siguiente:

“1. Los datos personales serán

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);”

Se entiende que el tratamiento de datos personales ha de ser limitado a lo necesario para lograr el objetivo, es decir, cuando el propósito no puede lograrse razonablemente sin el tratamiento de esos datos personales.

Se relaciona así con el principio de limitación de la finalidad del artículo 5.1.b) del RGPD, y solo conduce a resultados precisos si el propósito específico está bien definido por el responsable del tratamiento y se liga con la proporcionalidad y necesidad de dicho tratamiento.

La pertinencia del dato remite a su imprescindibilidad para obtener el resultado, debiéndose revisar las opciones que se ofrecen al responsable para adecuarse a ese principio en cada operación de tratamiento.

Cuando la entidad responsable sea un medio de comunicación, debe tener presente el citado principio de minimización de datos personales siempre que tenga prevista la utilización de datos personales en un artículo periodístico.

El presente procedimiento se inicia porque la entidad EL ESPAÑOL publicó, en el sitio web “elespanol.com”, una noticia sobre la divulgación de vídeos en redes sociales en cuyo texto se hacía referencia al nombre de la parte reclamante (“(...)”) y se ilustraba con una fotografía también de la parte reclamante, tomada de un vídeo que fue publicado y ampliamente difundido a través de la red social “Twitter”. La imagen de la parte reclamante se apreciaba con toda nitidez en dicha fotografía.

En el mismo artículo se insertan enlaces que conducen al vídeo en cuestión, en el que igualmente se muestra con toda nitidez la imagen y la voz de la parte reclamante, que no fueron debidamente anonimizadas mediante ninguna técnica adecuada para ello.

Según consta reseñado en el Hecho Probado Primero, el vídeo consiste en un montaje de tomas sucesivas (...).

*A este vídeo en concreto se refiere la noticia publicada por EL ESPAÑOL. Se trata de una información publicada el ***FECHA.2 en la web “elespanol.com” acompañada del repetido vídeo y una captura de pantalla tomada del mismo (incluye un enlace a la publicación del vídeo en “Twitter”, en el perfil correspondiente al usuario “***USUARIO.1”, “***USUARIO.1”, con el texto “(...)”, las indicaciones “(...)”, y un botón para compartir el contenido).*

En este artículo, EL ESPAÑOL informa sobre (i) el contenido del vídeo, destacando alguno de los diálogos que se mantienen entre las personas que aparecen en el mismo; (ii) su amplia difusión en redes sociales, que considera producida por su carácter divertido; y (iii) los miles de comentarios a que ha dado lugar, alguno de los cuales se transcriben en el mismo artículo.

EL ESPAÑOL debería haberse planteado si la finalidad de la información requería la difusión de la imagen y la voz de la parte reclamante contenida en el vídeo en cuestión sin haber aplicado sobre la misma algún proceso de anonimización, o si la indicación del nombre en el texto del artículo publicado era realmente necesaria para el propósito pretendido; o si este propósito, por el contrario, era perfectamente alcanzable sin la identificación del titular de los datos personales.

Esta Agencia entiende que la información que EL ESPAÑOL pretendió hacer llegar al público en general no requería esa utilización y difusión de los datos personales de la parte reclamante. En base a ello, resulta que se ha realizado un tratamiento de datos personales en clara vulneración del principio de minimización de datos.

Conclusión esta que no es compartida por EL ESPAÑOL. Esta entidad, en sus alegaciones a la apertura del presente procedimiento, no discute el tratamiento de datos personales realizado, pero sí el hecho de que éste pueda ser considerado como

constitutivo de infracción y, por tanto, ser objeto de sanción.

En primer lugar, destaca la entidad reclamada que el vídeo en cuestión fue difundido un mes antes (...), la cual también fue objeto de atención periodística en otros medios. EL ESPAÑOL da a entender que la difusión de este contenido a través de internet fue intencionada y que con esa difusión la parte reclamante logró “el propósito aparente deseado”.

Asimismo, destaca que el vídeo, en el que la propia parte reclamante alude a su nombre o sobrenombre “(...)”, se volvió tendencia en diferentes plataformas y redes sociales de seguimiento masivo (Twitter, Youtube, Tik Tok), siendo comentado y compartido por miles de usuarios, y continúa visible a través de miles de enlaces a los que puede accederse mediante un motor de búsqueda con el indicado sobrenombre como criterio. En base a ello, considera que la pérdida de disposición y control de los datos personales del interesado tuvo lugar con anterioridad a la publicación que ha dado lugar a las presentes actuaciones y no a consecuencia de la misma, cuestión esta que EL ESPAÑOL entiende esencial para determinar su responsabilidad. A este respecto, señala que la viralización de un contenido es un resultado conjunto de las acciones y reacciones de los usuarios en línea, por lo que no puede ser atribuida de manera directa ni exclusiva a EL ESPAÑOL.

Por otra parte, en relación con el principio de minimización de datos y su consideración en el presente caso, alega EL ESPAÑOL que los datos utilizados en la noticia publicada eran manifiestamente públicos y que no se utilizaron medios técnicos para impedir el reconocimiento de la imagen, debido a que el video en cuestión no fue originalmente subido ni alojado por esa parte, sino que se empleó la técnica de trasclusión, la cual se refiere a la inclusión de un video o documento de otro sitio web mediante la inserción del código correspondiente en la página web de EL ESPAÑOL.

Sin embargo, estas circunstancias, aunque se tomaran todas ellas como ciertas, no modifican la responsabilidad de EL ESPAÑOL por los hechos analizados, por cuanto ninguna de ellas excusa el cumplimiento de la normativa de protección de datos por parte de dicha entidad desde el mismo momento en que decide la recogida y utilización de los datos en cuestión. Tampoco el hecho de que puedan existir posibles responsabilidades de otros terceros, otras conductas sancionables, exime de responsabilidad a aquella entidad.

La existencia de posibles incumplimientos previos de terceros no exime al medio de comunicación de la obligación de realizar un análisis de riesgos previo a la publicación de la noticia. EL ESPAÑOL, como medio de comunicación y en calidad de responsable del tratamiento, decide qué y cómo publica. Podría decidir publicar el vídeo tal cual, optar por no publicarlo o decidir distorsionar la imagen y la voz de la parte reclamante a fin de evitar que sea reconocible por terceros.

Cualquier operación de tratamiento que se realice en el ámbito de la parte reclamada (en este caso la difusión de datos personales con ocasión de la noticia) debe imputarse solo a ella, con independencia de las operaciones de tratamiento que se hayan realizado previamente por otros sujetos y que, en ningún caso, le eximen de su responsabilidad. Los medios de comunicación, como responsables del tratamiento de múltiples datos que conocen dentro del ejercicio de su labor periodística, han de

conocer y cumplir con la normativa en materia de protección de datos, aplicando, entre ellos, el principio de minimización de datos consagrado en el artículo 5.1.c) del RGPD.

Debe señalarse, asimismo, que EL ESPAÑOL no tenía certeza de que el vídeo se hubiese difundido intencionadamente por la propia parte reclamante, dado que lo tomó de un usuario de la red social "Twitter" no identificado.

Incluso, de haberse producido esa difusión intencionada, tampoco puede interpretarse en el sentido pretendido por EL ESPAÑOL en sus alegaciones. En supuestos como este, sólo al interesado corresponde decidir sobre el uso de sus datos personales, según ha quedado expuesto, y esto no cambia por el hecho de que los datos personales se encuentren accesibles a través de Internet, con independencia de su origen.

En Sentencia núm. 91/2017, de fecha 15/02/2017, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre un supuesto en el que la parte demandada (medio de comunicación) utilizó una fotografía tomada del perfil de Facebook del demandante para ilustrar una noticia publicada en la edición en papel de un diario. En esta Sentencia se considera que el derecho a la información legitima la actuación del medio de comunicación, que proporciona información veraz sobre los hechos o personas de relevancia pública, relevancia que se atribuye a la información sobre hechos de trascendencia penal. Sin embargo, sobre la utilización de aquella fotografía declara lo siguiente

"Que en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya "subido" una fotografía suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet. La finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación.

El consentimiento del titular de la imagen para que el público en general, o un determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta..."

"La exigencia de tutelar el derecho de información no puede significar que se dejen vacíos de contenido los derechos fundamentales de quienes resulten afectados por el ejercicio de aquél, que solo han de sacrificarse en la medida en que resulte necesario para asegurar la información libre en una sociedad democrática, tal como establece el art. 10.2 del Convenio europeo de derechos humanos (SSTC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 5, y 121/2002, de 20 de mayo, FJ 4). Y el interés público que suscitaba el suceso violento y que justificaba que el diario de la demandada informara sobre el mismo, incluso con identificación de los afectados por el suceso, no exigía ni justificaba que se publicara la imagen de la víctima del suceso, obtenida en su perfil de una red social, sin su consentimiento expreso".

De la misma forma, tampoco influye la técnica empleada para capturar o dar difusión al vídeo. A este respecto, EL ESPAÑOL ha manifestado que el vídeo en cuestión no fue originalmente subido ni alojado por esa parte, sino que se empleó la técnica de trasclusión, la cual se refiere a la inclusión de un vídeo o documento de otro sitio web mediante la inserción del código correspondiente en la página web de EL ESPAÑOL.

Sobre esta cuestión, cabe indicar, por un lado, que la noticia publicada no solo incluyó el enlace que permitía acceder al vídeo en otro sitio web, sino que la noticia se ilustró con una fotografía de la parte reclamante tomada de dicho vídeo. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que la inclusión de estos enlaces constituye un tratamiento de datos personales, conforme a la definición de tratamiento establecido en el artículo 4 del RGPD, que considera como tal cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales como la “comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión”.

Sobre la utilización de esta técnica de trasclusión, señala también EL ESPAÑOL que el contenido no se transfiere a un público nuevo ni se divulga a través de una técnica específica diferente de la comunicación original, tal como interpretó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia de 13/02/2014, dictada en el asunto C-466/12 (conocida como Caso Svensson).

No obstante, esta Sentencia se pronuncia sobre cuestiones relativa a la propiedad intelectual, de modo que las interpretaciones que realiza, sobre las consecuencias que se derivan de la incorporación en un sitio de Internet de enlaces que conducen a contenidos protegidos por derechos de aquella naturaleza alojados en otros sitios, no son trasladables al presente caso. De cualquier forma, de lo declarado en esa Sentencia en relación con la utilización de estos enlaces, interesa destacar lo siguiente:

“20. De lo anterior se deduce que, en circunstancias como las del litigio principal, el hecho de facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas debe calificarse de «puesta a disposición» y, en consecuencia, de «acto de comunicación» en el sentido de la referida disposición”.

En otro orden, la entidad reclamada señala en sus alegaciones que ha demostrado su proactividad cumpliendo de manera inmediata la medida provisional ordenada por esta AEPD, eliminando el vídeo y todo el contenido de la publicación. Sin embargo, esta actuación, con la que EL ESPAÑOL simplemente da cumplimiento a la normativa y atiende las resoluciones de esta autoridad de control, de obligado cumplimiento, tampoco puede servir para modificar su responsabilidad por los hechos analizados.

V

Derecho fundamental a la libertad de información

EL ESPAÑOL, en sus alegaciones, pone de manifiesto que la popularización del vídeo se convirtió en un tema de interés público y periodístico, en tanto que fenómeno cultural y por su impacto social, motivando su única intención de informar a los lectores, sin comprometer la intimidad ni la dignidad de la parte reclamante y sin ahondar en su vida personal ni en aspectos personales sensibles y sin realizar ningún tipo de juicio de valor.

Añade que el enfoque del artículo publicado se centró en la popularidad e implicaciones sociales de aquella tendencia en redes, brindando a los lectores información actual y relevante, en cumplimiento de la labor del medio de comunicación.

Prueba de ello, según EL ESPAÑOL, es el hecho de que otros medidos también se hicieron eco de la misma tendencia.

Considera, asimismo, que la imagen y el nombre de la parte reclamante son elementos centrales del hecho noticiable, en el contexto de la información que se busca difundir, sin que ello implique una extralimitación en el ejercicio del derecho a la libertad de información.

Por otro lado, destaca que la jurisprudencia citada por esta Agencia para respaldar un tratamiento de datos que pueda considerarse excesivo se ha centrado en reproducciones de imagen en contextos penales, en las cuales los tribunales han sostenido que las imágenes en cuestión carecen de relevancia para la información a transmitir.

Sin embargo, en el presente supuesto, como expondremos, el tratamiento llevado a cabo por EL ESPAÑOL en el marco de la libertad de información ha sido excesivo, al no existir un interés público informativo en la difusión de la imagen y la voz de la parte reclamante, con indicación de su nombre. Mantener dicha imagen y voz sin anonimizar (sin desenfocar la imagen y sin distorsionar la voz, por ejemplo) no aporta valor añadido alguno a la información, bajo cuyo pretexto parece que se han divulgado aquellos datos, que hacen claramente identificable a la persona, más aún si se especifica el nombre.

Al ponderar los intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concurrentes de este caso, esto es, la naturaleza especialmente sensible de los datos personales y la afectación a la intimidad de la persona (la parte reclamante), merece mayor protección el interés del titular del derecho a la protección de sus datos personales y a que no se difundan frente al pretendido interés público en su difusión.

Es cierto que nos encontramos ante un derecho fundamental, el de la protección de datos personales, que no es absoluto, puesto que llegado el caso puede ceder ante la prevalencia de otros derechos y libertades también constitucionalmente reconocidos y protegidos, como, por ejemplo, el derecho fundamental a la libertad de información, ponderándose ello caso a caso.

En la pugna entre los derechos fundamentales a la libertad de información en relación con el derecho fundamental a la protección de datos personales, aun cuando se reconoce igual grado de protección de ambos derechos constitucionales, ordinariamente el primero suele ser dotado de prevalencia por nuestros tribunales, tras valorar y ponderar todos los elementos en juego.

Ahora bien, preponderancia no significa prevalencia cuando, atendidas todas las circunstancias concurrentes en un supuesto concreto, se rebasen los límites fijados normativa y jurisprudencialmente.

En este sentido, el Grupo del Trabajo del Artículo 29 en su Dictamen 06/2014 sobre el concepto de interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE, al examinar la base jurídica del interés legítimo del artículo 7.1.f) de la Directiva 95/46/CE, trasladable plenamente al actual art. 6.1.f) del RGPD, incluye el derecho a la libertad de expresión o de información como uno de los supuestos en los que puede surgir la cuestión del interés legítimo aseverando que “sin perjuicio de si los intereses del responsable del tratamiento prevalecerán en último término sobre los intereses y los derechos de los interesados cuando se realice la prueba de sopesamiento”.

. Límites al Derecho Fundamental a la Libertad de Información.

Dicho lo anterior, el derecho fundamental a la libertad de información tampoco es absoluto. Podemos observar límites clarísimos establecidos por los tribunales en el ámbito civil, en relación con el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Así, citaremos, por todas, la STC 27/2020, de 24 de febrero de 2020 (recurso de amparo 1369-2017) que dispone, en relación con la imagen de una persona, y partiendo del hecho incontrovertido de que la hace identificable, que “...la cuestión debatida se reduce a ponderar si la reproducción no consentida de la imagen de una persona anónima es decir, de alguien que no es personaje público, pero que adquiere repentina e involuntariamente un papel en el hecho noticiable, en este caso como víctima del fallido intento de homicidio por parte de su hermano y el posterior suicidio de este, supuso una intromisión ilegítima en su derecho fundamental a la propia imagen (art. 18.1 CE).

[...]

...que los sucesos criminales son acontecimientos noticiables, incluso con independencia del carácter de sujeto privado de la persona afectada por la noticia. Sin embargo, el límite está en la individualización, directa o indirecta, de la víctima, pues este dato no es de interés público porque carece de relevancia para la información que se permite transmitir (SSTC 20/1992, de 20 de febrero; 219/1992, de 3 de diciembre; 232/1993, de 12 de julio; 52/2002, de 25 de febrero; 121/2002, de 20 de mayo, y 127/2003, de 30 de junio). Así, actualmente lo reconoce la Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito, en vigor desde el 28 de octubre de 2015, cuando advierte de la necesidad «desde los poderes públicos [de ofrecer] una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica sino también social, a las víctimas, no solo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal. Por ello, el presente Estatuto, en línea con la normativa europea en la materia y con las demandas que plantea nuestra sociedad, pretende, partiendo del reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la defensa de sus bienes materiales y morales y, con ello, los del conjunto de la sociedad». En supuestos como los planteados en este recurso, este Tribunal debe otorgar relevancia a la prevalencia del derecho a la imagen de la víctima del delito frente a las libertades informativas, pues la información gráfica devenía ociosa o superflua por carecer la fotografía de la víctima de interés real para la transmisión de

la información, en este caso la realización aparente de un homicidio y posterior suicidio” (el subrayado es nuestro).

Añadiremos la STS, de su Sala Primera de lo Civil, 272/2011 de 11 de abril de 2011 (rec. 1747/2008), en la que, respecto de los datos necesarios para suministrar una información y los límites al interés público recoge que “b) La información trivial no se protege (ATC 75/2006), pero sí el hecho de facilitar datos no necesarios en un caso de violación (el nombre completo, las iniciales de los apellidos, el portal de la calle donde vivía la víctima) que no tienen relevancia comunitaria, no respetan la reserva, sólo buscan satisfacer la curiosidad, producen perturbaciones o molestias y desvelan de forma innecesaria aspectos de la vida personal y privada, permitiendo a los vecinos, personas próximas y familiares la plena identificación de la víctima y el conocimiento con lujo de detalles de un hecho gravemente atentatorio contra su dignidad (STC 185/2002) o sobre una enfermedad que no tiene interés público y afecta de manera directa al ámbito irreducible de la intimidad y que se revela al efecto de una pura broma o chanza (STC 232/1993);”.

Igualmente, la STS, de su Sala Primera de lo Civil, Sentencia 661/2016 de 10 de noviembre 2016 (rec. 3318/2014), en relación con la captación y divulgación en juicio de la imagen de una víctima de violencia de género dispuso que “1.ª) No se discute el interés de la información cuestionada ni el derecho de la cadena televisiva demandada a emitir imágenes grabadas durante el acto del juicio oral de la causa penal, ya que no consta ninguna limitación al respecto acordada por el órgano judicial.

2.ª) El único punto controvertido es, por tanto, si la identificación de la demandante como víctima de los delitos enjuiciados en dicha causa penal, mediante primeros planos de su rostro y la mención de 31/03/2022 su nombre de pila y lugar de residencia, estaba también comprendida en el derecho fundamental de la cadena de televisión demandada a transmitir información veraz o, por el contrario, quedaba limitada por los derechos fundamentales de la demandante a su intimidad personal y a su propia imagen.

3.ª) Respecto de esta cuestión la jurisprudencia ha reconocido el interés general y la relevancia pública de la información sobre causas penales (sentencia 547/2011, de 20 de julio), que se acentúan en los casos de maltrato físico y psicológico (sentencias 128/2011, de 1 de marzo, y 547/2011, de 20 de julio), pero también ha puntualizado, en cuanto a la identificación de las personas que intervienen en el juicio, que el acusado y la víctima no se encuentran en un plano de igualdad, pues en cuanto a aquel sí cabe una identificación completa, y no solo por sus iniciales, debido a la naturaleza y trascendencia social de los delitos de malos tratos (sentencia 547/2011, de 20 de julio).

[...]

6.ª) En definitiva, la cadena de televisión demandada debió actuar con la prudencia del profesional diligente y evitar la emisión de imágenes que representaban a la recurrente en primer plano, bien absteniéndose de emitir las correspondientes tomas, bien utilizando procedimientos técnicos para difuminar sus rasgos e impedir su reconocimiento (sentencia 311/2013, de 8 de mayo). De igual modo, también debió evitar la mención de su nombre de pila, porque este dato, insuficiente por sí solo para

constituir intromisión ilegítima, pasó a ser relevante al pronunciarse en pantalla simultáneamente con la imagen de la demandante y añadirse la mención de su localidad de residencia, datos todos ellos innecesarios para la esencia del contenido de la información, como demuestran las noticias sobre el mismo juicio publicadas al día siguiente en otros medios. 7.ª) La identificación de la demandante mediante su imagen y los datos personales indicados y su directa vinculación con un episodio de violencia de género y otros delitos graves, cuando era previsible la revelación simultánea o posterior de datos referidos a cómo se conocieron la víctima y su agresor y a la forma en que sucedieron los hechos delictivos, supone que la pérdida del anonimato vulnerase tanto el derecho de la demandante a su propia imagen, por la emisión de sus rasgos físicos, como su intimidad personal y familiar, en la medida en que unos datos reservados, pertenecientes a su vida privada (que acudió a Internet para iniciar una relación o el contenido íntimo de algunas de sus charlas), carentes de entidad ofensiva en una situación de anonimato, pasaron a tenerla desde el momento en que cualquier persona que viera esos programas informativos y que residiera en la localidad de la víctima podía saber a quién se referían, de modo que al daño psicológico inherente a su condición de víctima de los delitos se sumó el daño moral consistente en que se conocieran datos de su vida privada que no había consentido hacer públicos". (el subrayado es nuestro).

Como podemos comprobar, se hace una clara referencia al tratamiento excesivo de datos personales (algunos no son de naturaleza íntima) para suministrar la información, considerándolos innecesarios a todo punto en atención a las circunstancias concurrentes. En ocasiones los tribunales se refieren a datos íntimos, pero en ocasiones se trata de datos personales que no son íntimos, como, por ejemplo, la imagen de una persona física obtenida de una fotografía publicada en una red social o el nombre y los apellidos.

. Equilibrio entre el derecho fundamental a la libertad de información y el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

En el caso concreto examinado, tal y como hemos indicado, la entidad EL ESPAÑOL publicó, en el sitio web referido en los hechos, la imagen de la parte reclamante para ilustrar una noticia sobre redes sociales, en la que, además, se menciona su nombre, insertando enlaces que conducían al vídeo objeto la reclamación que ha motivado el presente procedimiento sancionador.

Así, no se trata, como en otros supuestos jurisprudencialmente examinados, de dotar de prevalencia a un derecho fundamental sobre otro, debiendo elegir cuál tiene más peso en un supuesto específico, sino, más bien, de encontrar un equilibrio entre ambos para lograr la consecución de la finalidad del primero sin desvirtuar el segundo. La conciliación de ambos derechos no es nada nuevo, puesto que el legislador europeo mandata tal conciliación en el artículo 85 del RGPD.

Como hemos visto anteriormente, el derecho fundamental a la libertad de información no es ilimitado, puesto que la interpretación jurisprudencial al confrontarlo con otros derechos y libertades no permite en todo caso y con toda amplitud el mismo, sino que, no obstante, la prevalencia que suelen dotarle los tribunales puede verse limitado por otros derechos fundamentales que deben también ser respetados. Así se observa su limitación cuando los datos personales facilitados eran innecesarios para la esencia

del contenido de la información.

En este caso, la imagen de la parte reclamante y su voz, así como su nombre, sin constreñir el suministro de información, debe hacerse compatible con el principio de minimización de datos, aplicable sobre la forma, el medio en que se suministra y difunde la información por la afectación inmediata al dato personal y a la identificación de la persona.

Precisamente porque no se niega el interés público informativo en la noticia, en este caso concreto, no se trata de hacer decaer el derecho fundamental a la libertad de información por la prevalencia del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, sino de hacerlos plenamente compatibles para que ambos queden absolutamente garantizados. Esto es, no se pone en cuestión la libertad de información de los medios de comunicación sino la ponderación con el derecho a la protección de datos en base a la proporcionalidad y necesidad de publicar el concreto dato personal de la imagen o el nombre de la persona. Tal situación podría haberse resuelto con la utilización de procedimientos técnicos para impedir el reconocimiento de la imagen y la voz, medidas de seguridad ambas, aplicadas dependiendo del caso de forma ordinaria por los medios de comunicación, y con la no indicación del nombre de la parte reclamante.

A mayores, hemos de significar que la parte reclamante es una persona anónima y nuestro Tribunal Constitucional, por todas STC 58/2018 de 4 de junio, afirma que las autoridades públicas, los funcionarios públicos y los personajes públicos o dedicados a actividades que conllevan notoriedad pública “aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta moral participan del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin vocación de proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito superior de privacidad, que impide conceder trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidos a personajes públicos”.

La STJUE (Sala Segunda) de 14 de febrero de 2019, en el asunto C 345/17, Sergejs Buivids hace mención a diversos criterios para ponderar entre el derecho al respeto de la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, entre los cuales se encuentran “la contribución a un debate de interés general, la notoriedad de la persona afectada, el objeto del reportaje, el comportamiento anterior del interesado, el contenido, la forma y las repercusiones de la publicación, la forma y las circunstancias en las que se obtuvo información y su veracidad (véase, en este sentido, la sentencia del TEDH de 27 de junio de 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy y Satamedia Oy c. Finlandia, CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, apartado 165)”.

Así, un asunto puede ser considerado de interés general, de relevancia pública, no sólo por la persona que intervenga, sino también por la materia a la que se refiere. Deben concurrir ambos requisitos.

En el presente caso, (i) la parte reclamante no es una persona pública; más bien al

contrario, es de interés que no sea reconocida por terceras personas, de tal forma que se garanticen plenamente sus derechos fundamentales; es decir, no estamos ante un personaje de relevancia pública, en el sentido de que tal relevancia sea suficiente para entender que supone, ex lege, una desposesión de su derecho fundamental a la protección de sus datos personales, y (ii) aunque estemos ante hechos “de relevancia pública”, en el sentido de que se revelen como “necesarios” para la exposición de las ideas u opiniones de interés público, esa necesidad no alcanza a que se faciliten datos que identifiquen a la parte reclamante

Por ello, y como expresa el Tribunal Supremo en su sentencia (civil) 697/2019, de 19 de diciembre de 2019, la formación de una opinión pública libre no exige, ni justifica, que se afecte al derecho fundamental a la propia imagen [en este caso a la protección de datos personales] con esa gravedad y de un modo que no guarda la necesaria conexión con la identificación de la persona objeto de la información.

VI

Tipificación y calificación de la infracción a los efectos de la prescripción

De conformidad con las evidencias expuestas, en el presente caso, se considera que EL ESPAÑOL ha tratado datos que eran excesivos al no ser necesarios para la finalidad para la que se trataban.

Así, los hechos constatados son constitutivos de una infracción, imputable a EL ESPAÑOL, del artículo 5.1.c) del RGPD, con el alcance expresado en los Fundamentos de Derecho anteriores, lo que supone la comisión de la infracción tipificada en el artículo 83.5, apartado a) del RGPD, que bajo la rúbrica “Condiciones generales para la imposición de multas administrativas” dispone que:

“Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:

a) los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9;

A este respecto, la LOPDGDD, en su artículo 71 establece que “Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten contrarias a la presente ley orgánica”.

A efectos del plazo de prescripción, el artículo 72 de la LOPDGDD indica:

Artículo 72. Infracciones consideradas muy graves.

“1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes:

a) *El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679”.*

VII Sanción

A fin de determinar la multa administrativa a imponer se han de observar las previsiones de los artículos 83.1 y 83.2 del RGPD, preceptos que señalan:

“1. Cada autoridad de control garantizará que la imposición de las multas administrativas con arreglo al presente artículo por las infracciones del presente Reglamento indicadas en los apartados 4, 9 y 6 sean en cada caso individual efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el artículo 58, apartado 2, letras a) a h) y j). Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta:

- a) la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido;*
- b) la intencionalidad o negligencia en la infracción;*
- c) cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados;*
- d) el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32;*
- e) toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento;*
- f) el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;*
- g) las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción;*
- h) la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida;*
- i) cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas;*
- j) la adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación aprobados con arreglo al artículo 42, y*
- k) cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción”.*

Respecto al apartado k) del artículo 83.2 del RGPD, la LOPDGDD, artículo 76, “Sanciones y medidas correctivas”, dispone:

“1. Las sanciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 se aplicarán teniendo en cuenta los criterios de graduación

establecidos en el apartado 2 del citado artículo.

2. De acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2.k) del Reglamento (UE) 2016/679 también podrán tenerse en cuenta:

- a) El carácter continuado de la infracción.*
- b) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos personales.*
- c) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.*
- d) La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la comisión de la infracción.*
- e) La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión de la infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente.*
- f) La afectación a los derechos de los menores.*
- g) Disponer, cuando no fuere obligatorio, de un delegado de protección de datos.*
- h) El sometimiento por parte del responsable o encargado, con carácter voluntario, a mecanismos de resolución alternativa de conflictos, en aquellos supuestos en los que existan controversias entre aquellos y cualquier interesado”.*

En este caso, considerando la gravedad de la infracción constatada, atendiendo especialmente a las consecuencias que su comisión provoca en la parte reclamante, procede la imposición de multa, además de la adopción de medidas.

La multa que se imponga deberá ser, en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria, conforme a lo establecido en el artículo 83.1 del RGPD. Así, se considera, con carácter previo, la condición de mediana empresa y el volumen de negocio de la parte reclamada (...).

De acuerdo con los preceptos indicados, a efectos de fijar el importe de la multa a imponer en el presente caso, se considera que procede su graduación de acuerdo con los siguientes criterios que establecen los preceptos transcritos:

- *Artículo 83.2.a) del RGPD:*

Naturaleza, gravedad y duración de la infracción: la Agencia considera que la naturaleza de la infracción es muy grave puesto que acarrea a la persona una pérdida de disposición y control sobre los datos personales, al ser difundidos a través de internet sin restricciones.

- *Artículo 83.2.b) del RGPD.*

Intencionalidad o negligencia en la infracción: si bien la Agencia considera que no hubo intencionalidad por parte del medio de comunicación, se concluye que fue negligente al no asegurar un procedimiento que garantizase la protección de los datos personales en unas circunstancias tan sensibles.

- *Artículo 83.2.g) del RGPD.*

Categorías de datos personales afectados por la infracción: si bien no se han visto afectadas “Categorías especiales de datos personales”, según define el RGPD en el

artículo 9, los datos personales a los que se refieren las actuaciones (imagen y voz de la parte reclamante) tiene una naturaleza especialmente sensible, por cuanto permite la pronta identificación de la persona y aumenta los riesgos sobre su privacidad.

Considerando los factores expuestos, la valoración que alcanza la multa por la infracción del artículo 5.1.c) del RGPD es de 10.000 euros (diez mil euros)>>.

En su escrito de recurso, la parte recurrente se limita a reproducir los argumentos expuestos en los escritos de alegaciones presentados durante la tramitación del procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada, sin considerar los hechos constatados y los fundamentos que sirven de base al acuerdo adoptado, en los que, además, se analizan ampliamente las circunstancias puestas de manifiesto por dicha parte y se exponen las razones que determinaron su desestimación.

Por tanto, los alegatos contenidos en el recurso quedan sobradamente rebatidos con los argumentos transcritos, que se consideran válidos y suficientes para rechazar la nulidad de la resolución sancionadora solicitada, por cuanto no resultan lesionados los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

El recurso ahora examinado se fundamenta, nuevamente, en los principios y criterios jurisprudenciales que se valoran para la ponderación de los derechos al honor, intimidad y propia imagen frente a las libertades de información y expresión, los cuales, si bien pueden ser orientadores, no son trasladables al presente caso en la forma pretendida por EL ESPAÑOL y no sustituyen ni desplazan los principios que informan el orden normativo en materia de protección de datos personales, que son directamente aplicables y cuya vulneración puede ser objeto de sanción.

Con este planteamiento no niega la AEPD, como bien razona en su resolución, que los principios de protección de datos personales puedan verse limitados por las libertades de expresión e información, según la ponderación de estos derechos que corresponde realizar, en cada caso, cuando tales derechos entran en colisión. Así, se comparte la afirmación manifestada por EL ESPAÑOL sobre la posibilidad de que un medio de comunicación publique datos personales cuando resulten necesarios para proporcionar la información de que se trate.

Es esta, precisamente, la cuestión valorada para la determinación de la infracción sancionada en la resolución recurrida, en la que se concluye después de analizadas las circunstancias específicas del caso, según queda expuesto en los fundamentos transcritos, que el tratamiento de la imagen y voz del interesado no era necesario para la finalidad informativa pretendida con la publicación de la noticia objeto de las actuaciones.

Frente a lo anterior, EL ESPAÑOL mantiene el planteamiento al que se acogió en sus escritos de alegaciones a la apertura del procedimiento y propuesta de resolución formalizadas en el procedimiento impugnado. Así, considera EL ESPAÑOL que el análisis del caso debe realizarse atendiendo únicamente a lo que denomina “requisitos legitimadores” del derecho a la libertad de información, a saber, la relevancia, interés público y veracidad de la noticia, a los que entiende debe someterse la normativa de protección de datos. Llega a afirmar que imponer una sanción coarta aquella libertad y

que el principio de minimización de datos, considerando las obligaciones que conlleva, no puede ser cumplido por un medio de comunicación.

En apoyo de dicho planteamiento, acude EL ESPAÑOL a la posibilidad de establecer excepciones a la normativa de protección de datos personales cuando el tratamiento se realiza con fines periodísticos o por profesionales de la información, reflejada en los Considerandos 4 y 153 y artículo 85 del RGPD.

De ser atendido, dicho planteamiento supondría en la práctica la no aplicación de la normativa de protección de datos personales al ejercicio periodístico y podría dar lugar a la publicación indiscriminada de datos personales sin ningún tipo de limitación.

Todo ello fue respondido de contrario en el Fundamento de Derecho II de la resolución impugnada, que recoge la respuesta de la AEPD a las alegaciones a la propuesta de resolución formuladas por EL ESPAÑOL, al que cabe ahora remitirse.

No obstante, se estima oportuno reiterar y destacar de nuevo, en primer término, que la AEPD no entiende cuáles son los motivos que impiden a un medio de comunicación atender los principios relativos al tratamiento de datos personales, regulados en el artículo 5 del RGPD, entre los que se incluye, por lo que aquí interesa, el principio de minimización de datos, que obliga a reducir el tratamiento a aquellos datos que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Debe aclararse que EL ESPAÑOL no expresa en su recurso ninguna razón para la no aplicación de este principio a los tratamientos de datos personales que conlleva el ejercicio de su actividad como medio de comunicación, a diferencia de lo expresado en sus alegaciones anteriores, en las que se aducían simples razones de tipo económico o humano, como el desconocimiento de la norma por parte de los profesionales del medio, que no se mencionan ahora en su escrito de recurso, las cuales no se estimaron suficientes, obviamente, para aceptar el enfoque defendido por la entidad recurrente.

Por otro lado, es pertinente añadir que las previsiones recogidas en el RGPD en los Considerandos 4 y 153 y en su artículo 85 del RGPD, sobre la posibilidad de que los Estados miembros establezcan excepciones y exenciones de lo dispuesto en esta norma para tratamiento realizados con fines periodísticos, tienen como motivación el establecimiento de una regulación específica para equilibrar y conciliar el derecho a la protección de datos personales con la libertad de expresión e información. Mandato este, el de la necesidad de conciliar estos derechos, que ha sido respetado en la resolución que da lugar al presente recurso, sin renunciar al análisis de los “requisitos legitimadores” del derecho a la libertad de información mencionados por EL ESPAÑOL, que han sido tenidos en cuenta en este caso, como claramente puede apreciarse en los Fundamentos de la resolución, y en otros de naturaleza similar, habiéndose resultado en ocasiones que el derecho a la libertad de información primaba sobre el derecho a la protección de datos, según las circunstancias concurrentes en cada supuesto individualmente considerado. No puede decirse por ello, como hace EL ESPAÑOL en su recurso, que la resolución que nos ocupa supone un cambio de criterio respecto de actuaciones precedentes.

En la resolución impugnada también se da respuesta a otras cuestiones reiteradas en el recurso, como la relativa a la profesionalidad que se atribuye a un medio de

comunicación y el efecto que conlleva en el nivel de cumplimiento normativo que puede exigírsele en la materia que tratamos. Sobre esta cuestión considera EL ESPAÑOL que la AEPD le exige un mayor grado de diligencia y que lo hace en base a una sentencia dictada en un caso de inclusión de datos en un fichero de información crediticia, cosa que es cierta. Sin embargo, el supuesto de hecho que dio lugar a la sentencia de la Audiencia Nacional invocada en la resolución no resta ninguna validez a la declaración de carácter general que formula cuando señala que *“en la valoración del grado de diligencia ha de ponderarse especialmente la profesionalidad o no del sujeto”*.

Esta valoración que realiza la resolución no supone imponer a un medio de comunicación exigencias que no se apliquen igualmente a otra entidad con un mismo grado de profesionalidad, perteneciente a cualquier otro sector de actividad. En todo caso, como ya se indica en la resolución impugnada, *“no es la AEPD, como señala EL ESPAÑOL, la que exige esta responsabilidad especial, sino que es la propia norma aplicable la que valora circunstancias tales como el riesgo o la profesionalidad, ya señaladas, el contexto o el estado de la técnica, entre otras”*.

Por otra parte, defiende EL ESPAÑOL en su escrito de recurso la pertinencia de los datos tratados en atención a la condición de personaje público del interesado y la necesidad del uso y difusión de su imagen y voz, así como por la accesoriedad de las imágenes que ilustraron la información publicada.

Asegura EL ESPAÑOL que la condición de “particular anónimo” del interesado se pierde con la viralización del vídeo que ya se había producido cuando se publica su noticia en la web “elespañol.com”, en referencia al concepto de “relevancia sobrevenida”.

No comparte esta AEPD que la viralización del vídeo en cuestión haga perder al interesado su condición de persona particular y anónima y le convierta en una persona de relevancia pública. En todo caso, aunque así fuera, no se justifica la publicación de dicho vídeo sin someterlo a un proceso de anonimización de los datos personales del interesado por cuanto las imágenes que se muestran pertenecen estrictamente al ámbito de su intimidad. Ya se sabe que para la publicación de imágenes no basta con que el interesado sea una persona con relevancia pública, sino que es necesario, además, que la imagen muestre un acto relacionado con la actividad pública de la persona o relacionado con un suceso público.

Insiste, asimismo, EL ESPAÑOL en señalar que no se entiende que la resolución sancionadora mantenga que no es posible acreditar la participación de la parte reclamante en la viralización del vídeo. Sin embargo, no existe en las actuaciones ninguna prueba que acredite la voluntad de dicha parte reclamante en la difusión realizada del vídeo, el cual fue subido a una red social por una tercera persona sin que nada muestre que la parte reclamante participara en este hecho.

Además, aunque la parte reclamante lo hubiese difundido en sus propios perfiles de redes sociales, esta difusión no legitima el uso posterior por un medio de comunicación sin disponer del consentimiento previo del interesado para ese uso de sus datos personales, divulgándolos en una forma distinta, según resulta de lo declarado por el Tribunal Supremo en Sentencia núm. 91/2017, de fecha 15/02/2017,

ya citada en la resolución que motiva el recurso.

En la Sentencia del Tribunal Supremo 593/2022, de 28 de julio, relativa a la publicación por un medio de comunicación de un vídeo subido a Youtube con la anuencia del actor, citada por la parte recurrente, se trata la cuestión relativa al papel que desempeñan las redes sociales en internet y su impacto en los derechos fundamentales. En ella se cita la STC 27/2020, de 24 de febrero, como sigue:

“La precitada STC 27/2020, de 24 de febrero, hace referencia a este nuevo panorama, con respecto a plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o Tuenti. De su lectura cabe obtener, en síntesis, la siguiente doctrina constitucional:

- (i) Los usuarios de las redes sociales continúan siendo titulares de derechos fundamentales y su contenido sigue siendo el mismo que en la era analógica.*
- (ii) El hecho de que circulen datos privados por las redes sociales en Internet no significa que lo privado se haya tornado público, puesto que el entorno digital no es equiparable al concepto de “lugar público” del que habla la Ley Orgánica 1/1982, ni puede afirmarse que los ciudadanos de la sociedad digital hayan perdido o renunciado a los derechos protegidos en el art. 18 CE.*
- (iii) El reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales comprendidos en el art. 18 CE, conlleva la potestad de la persona de controlar los datos que circulan en la red social y que le conciernen.*
- (iv) Salvo que concurra una autorización inequívoca para la captación, reproducción o publicación de la imagen por parte de su titular, la injerencia en el derecho fundamental a la propia imagen debe, necesariamente, estar justificada por el interés público preponderante en tener acceso a ella y en divulgarla.*
- (v) El titular del derecho fundamental debe autorizar el concreto acto de utilización de su imagen y los fines para los que la otorga. El consentimiento prestado, por ejemplo, para la captación de la imagen no se extiende a otros actos posteriores, como por ejemplo su publicación o difusión. De la misma manera, debe entenderse que la autorización de una concreta publicación no se extiende a otras, ya tengan la misma o diversa finalidad que la primigenia. Tampoco el permiso de uso otorgado a una persona determinada se extiende a otros posibles destinatarios. En definitiva, hay que entender que no puede reputarse como consentimiento indefinido y vinculante aquel que se prestó inicialmente para una ocasión o con una finalidad determinada”.*

Tampoco discute esta Agencia la difusión del vídeo junto con la noticia publicada. Se trata, simplemente, de exigir el establecimiento de garantías adecuadas para la protección de los datos personales sometidos a tratamiento con la utilización de dicho contenido audiovisual, con su publicación; garantías que, en este caso, no desnaturalizan el interés informativo de la noticia. Con ello, la AEPD ejerce las facultades que la norma le atribuye como autoridad de control en materia de protección de datos personales, que no suponen en modo alguno la realización de ningún tipo de control sobre los contenidos de las informaciones publicadas por medios de comunicación.

En cuanto a la accesoriedad de las imágenes alegada por EL ESPAÑOL, se trata también de un concepto relacionado con el derecho al honor, intimidad y propia imagen, como reconoce la propia entidad recurrente, que ha sido interpretado por nuestra jurisprudencia, admitiéndose la publicación de imágenes de personas

anónimas para acompañar una noticia periodística siempre que no se vea afectada la intimidad de la persona y ésta no constituya el objeto principal de la información, lo contrario de lo que ocurre en el caso que nos ocupa.

Por último, en cuanto al importe de la multa impuesta, que la parte recurrente considera desproporcionado, ninguna mención hace el recurso a los factores y criterios de graduación apreciados en la resolución, y tampoco a las razones que llevaron a la desestimación de aquella supuesta falta de proporcionalidad, que ahora se plantea nuevamente en base a las mismas circunstancias rechazadas en la resolución, algunas de las cuales están más relacionadas con las cuestiones de fondo que han determinado la infracción que con las propias circunstancias que llevaron a la determinación del importe de la sanción.

III

Conclusión

En consecuencia, en el presente recurso de reposición, la parte recurrente no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

IV

Resolución extemporánea

Debido a razones de funcionamiento del órgano administrativo, por ende no atribuibles a la parte recurrente, hasta el día de la fecha no se ha emitido el preceptivo pronunciamiento de esta Agencia respecto al presente recurso.

De acuerdo con lo establecido en el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) el sentido del silencio administrativo en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones es desestimatorio.

Con todo, y a pesar del tiempo transcurrido, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, según dispone el art. 21.1 de la citada LPACAP.

Por tanto, procede emitir la resolución que finalice el procedimiento del recurso de reposición interpuesto.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos **RESUELVE**:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. contra la resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 19 de junio de 2024, en el expediente EXP202309208.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A.

TERCERO: Advertir al sancionado que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva una vez sea notificada la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringida nº ES00 0000 0000 0000 0000, abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en el Banco CAIXABANK, S.A. o en caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo.

Si la fecha de la notificación se encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada LPACAP. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

180-21112023

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos